

1500272-07.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500272-07.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035436/2022 - DEL.POL.FLORÍNIA, 22876279 - DEL.POL.FLORÍNIA, 15/22/107 - DEL.POL.FLORÍNIA, 2035436 - DEL.POL.FLORÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO LAIOLA e outros

Vítima:

DAVI CARLOS DA SILVA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 07 de abril de 2022, às 14h, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, os réus Carlos Eduardo Laiola e Wellington Lucio Silva Palazzin, apresentado para a teleconferência pela Penitenciária de Assis, nas dependências daquela unidade, os advogados, Dr. José Roberto Magalhães

Prado, OAB/SP 353.632, Dr. Guilherme Afonso Domingues Mendes, OAB/SP 436.822, a vítima Sr. Davi Carlos da Silva, e as testemunhas Alvaro Francisco da Silva, Eduardo Henrique Gaiteiro Nogueira, Celma de oliveira Souza, Ana Carolina de Oliveira Moraesm. O MM Juiz indeferiu a oitiva das testemunhas Maria Alessandra Miranda e Cibele Marinho, uma vez que operada a preclusão consumativa. Iniciados os trabalhos, procedeu-se a oitiva da vítima, das testemunhas, ao interrogatório dos acusados e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Carlos Eduardo Laiola e Wellington Lucio Silva Palazzin, qualificados nos autos, por terem, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal. Narrou na denúncia que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Nicodemos Cornélio Assis, nº 27, Jardim Alvorada, na cidade de Florínea, nesta Comarca, Carlos Eduardo e Wellington, agindo em concurso e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair para si, bens de valor pertencentes a Davi Carlos da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta que os denunciados viram a vítima fechando a mercearia e decidiram praticar a subtração; um dos denunciados deu cobertura no lado de fora enquanto o outro anunciou o assalto, na posse de uma arma de fogo, e exigiu que a vítima fechasse o portão e lhe passasse a chave do veículo Saveiro; a vítima demonstrou irresignação e foi agredida com coronhadas na cabeça; houve luta corporal e os assaltantes evadiram-se sem levar nada, num veículo VW/Gol, placas AJG-2562, cor prata; na posse das características do veículo, a polícia militar os abordou na Rodovia SP 333, na divisa entre Tarumã e Assis, acompanhados de duas mulheres. A denúncia foi recebida em 10/02/2022 (fls.144/145). Citados, os réus apresentaram defesa preliminar (fls.195/198 e 203). Nesta data foi feita a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório dos réus. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação dos réus, sob os argumentos de que a vítima e testemunhas narraram uma tentativa de roubo; a vítima repetiu tudo que havia dito e o reconhecimento pessoal feito na delegacia as fls.19/20, confirmou que estavam em dois indivíduos, um armado e que sofreu coronhada do roubador; a vítima falou que antes de fazer o reconhecimento havia passado as características físicas e adereços que usavam, os quais foram apreendidos na posse dos réus; a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos na clandestinidade; a fl.39 constam fotos dos bonés e das máscaras, são os mesmos reconhecidos pelas vítimas; a testemunha Celma confirmou os fatos narrados pela vítima e a testemunha Ana Carolina reconheceu os réus, os objetos de fls.39 e o veículo de fl.43 como sendo o usado no assalto; os policiais fizeram a abordagem com base nas informações prestadas pela vítima e narraram que ele descumpriu sinal de parada; deve a pena ser aumentada pelo elevado grau de culpabilidade porque além da grave ameaça eles usaram violência real contra a vítima, causando as lesões indicadas na foto de fl.40; a circunstância do crime ter sido cometido em residência familiar torna o crime mais grave porque a vítima se sente arrebatada no local em que se presume estar mais segura, gera ambiente propício para arrebatamento e consequências ao ser humano que não vê mais no local de descanso um local seguro; os réus são reincidentes e tem maus antecedentes; deve ser aplicada a agravante do crime cometido durante período de pandemia e as consequências da pandemia e redução do fluxo de pessoas facilita crimes como este; ficaram provadas as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo; é irrelevante a ausência de apreensão da arma; incide a redução relativa à tentativa; deve ser fixado o regime inicial fechado, vedada a substituição da pena. A douta Defesa do réu Carlos solicitou a absolvição dele por falta de provas. Sustentou que os militares narraram

que os réus negaram os fatos durante a abordagem; a jurisprudência tem entendido que o reconhecimento fotográfico, sozinho, não tem como embasar a condenação criminal; foram repassadas para as vítimas apenas as fotos dos acusados. A douta Defesa do réu Wellington requereu a absolvição, sob as alegações de que: as vítimas foram contraditórias; há dúvida sobre a autoria; o reconhecimento fotográfico foi nulo porque deveria ser corroborado por outros elementos em Juízo; segundo o STJ o reconhecimento fotográfico, mesmo se confirmado em juízo, é imprestável; o reconhecimento foi feito de forma arbitrária e ilegal; há contradições das vítimas com relação às vestes dos assaltantes, ela disse que estavam de blusas e as testemunhas de camiseta; as fotos foram tiradas e nesse momento é que a vítima soube que havia outra mulher; em Juízo ela falou que viu estas mulheres sentadas na praça; a Ana Carolina primeiro disse que entrou na casa e depois em Juízo falou que foi atrás deles; o reconhecimento de Celma foi contraditório; nenhum objeto foi roubado e nada foi localizado no veículo; os policiais não viram os réus dispensar arma e estavam com vestimentas diversas do que foi declarado; as características apontadas pelas vítimas são frágeis; não houve confissão e identificação idônea pela vítima; foi contraditório a testemunha Ana Carolina ter dito que estava a apenas um metro e depois que reconheceu o assaltante pelos olhos; as declarações da vítima e testemunha estão isoladas; deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo; deve ser afastada a majorante do concurso de causas e aplicar apenas uma delas; deve ser afastada a causa de aumento de pena do emprego de fogo porque não foi apreendida; não é suficiente para exasperação a mera indicação das majorantes, por existir mais de uma; o réu sempre colaborou e deve ser aplicada a pena no mínimo legal e fixado o regime inicial aberto e ser concedido o direito de apelar em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente. A materialidade do delito foi provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.02/05), auto de exibição e apreensão (fls.06/07). A autoria do crime é certa e atribuída aos acusados, conforme se extrai dos autos de reconhecimento (fls.19/23) e relatos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Carlos Eduardo negou o crime. Afirmou que estava num bar, encontrou com Wellington e ele ligou para duas meninas sair com elas. Relatou que foram num bar em Tarumã, saindo de lá voltaram para Assis novamente e foram abordados pela polícia próximo ao Cabral. Negou ter havido perseguição. Negou ter assaltado a vítima Davi. Falou que a polícia já o colocou deitado no chão, chamou seu apelido e já é conhecido no meio policial, eles tiraram uma foto e mandaram para a vítima. Negou ter ido até Florínea. Negou saber como a vítima e testemunha lhe reconheceu. Disse que esteve em Florínea uma vez sete dias depois de ter saído. Negou ter passado pela estrada que vai a Florínea. Negou conhecer a vítima e testemunha Ana Carolina e que tenham motivos para lhe prejudicar. Ressaltou que tem dois filhos, trabalha com pintura. Destacou que estava com camisa verde, bermuda e chinelo. Negou ter percebido que estava sendo perseguido, a viatura que deu voz de parada veio pela contramão. Informou que tem condenação por tentativa de homicídio e tem renda de R\$ 1200. Em seu interrogatório o réu Wellington negou o crime. Negou ter estado em Florínia assaltando. Relatou que tinha brigado com a esposa, foi para o bar beber e jogar sinuca, começou a conversar com a Keterin pelo telefone e a chamou para sair. Mencionou que Carlos chegou com o carro e o chamou para sair com as meninas "tirar uma brisa". Declarou que foram na casa das meninas, foram para Tarumã, lá pararam na praça e fumaram maconha. Salientou que quase chegando no pesqueiro Globo a polícia deu sinal de luz, o giroflex não estava ligado. Contou que logo encostou o carro, a polícia mandou deitar com a cara no chão, não estavam sabendo de nada e falaram que tínhamos arrumado briga. Narrou que os policiais tiraram fotos e ficaram no chão, depois falaram que houve reconhecimento no assalto em Florínea. Disse que os policiais

falaram que nosso passado condenava. Negou ter estado em Florínea. Negou conhecer a vítima e testemunha e não sabe o motivo pelo qual foi reconhecido. Informou que estava com tênis da Nike, bermuda, camiseta do Corinthians e boné. Negou que tenham sido acompanhados pelos policiais desde Tarumã. Admitiu que foi condenado por

assalto duas vezes, ficou quase sete anos preso e abriu firma, vende coisas na internet e tem renda de R\$ 3 a R\$ 4 mil. A vítima Davi afirmou que ao colocar o carro para dentro da garagem eles chegaram armados querendo que fechasse o portão, queriam entrar de todo jeito. Relatou que não fechou e eles deram coronhada na sua cabeça, houve empurrões e eles correram. Falou que o depoente foi atrás deles, eles entraram num carro e viu duas mulheres. Declarou que na hora que começaram a falar desceu a máscara, reconheceu eles na delegacia, pois tinham vindo um dia antes comprar bebida. Contou que eles estavam com um 38 cor prata, cor prata. Ressaltou que ficou com ferimento na testa e na cabeça. Disse que estavam em dois, um lhe rendeu e o outro ficou no portão. Informou que estavam de blusa de frio, boné e máscara, na hora que apavorou a máscara caiu da cara. Informou que os reconheceu pelo rosto e eles já tinham vindo no bar no dia anterior. Explicou que a luta corporal foi com o Carlos. Narrou que fez o reconhecimento no mesmo dia e havia duas pessoas. Esclareceu que viu as mulheres, uma era branca com cabelo liso e outra tinha cabelo cacheado. Falou que eles chegaram mandando calar a boca e fechando o portão. Afirmou que um estava com boné escuro e outro com boné branco xadrez, blusa de frio, um com máscara branca e outra máscara preta, uma descartável e outra de pano. Negou ter feito exame de corpo de delito, mas tiraram foto. Declarou que o carro estava na esquina, uma das meninas estava dirigindo, os réus entraram no banco de trás. Salientou que recebeu as fotos, reconheceu os dois, também reconheceu o veículo, tinha foto com máscara e sem máscara. Ressaltou que passou as características dos indivíduos antes do reconhecimento. Explicou que mandaram as fotos apenas dos dois e eles foram abordados em seguida na pista. A testemunha Álvaro afirmou que estava em patrulhamento quando foi irradiada ocorrência de tentativa de roubo em Florínea e que se evadiram num Golf prata sentido Tarumã. Relatou que se posicionou na pista e abordou quase na entrada de Assis. Mencionou que mandou fotos para a vítima, ela reconheceu os dois e o carro. Declarou que no carro estava o réu Laiola, outro réu e duas meninas. Disse que eles negaram a participação do roubo e estar em Florínea, falaram que estavam num bar em Tarumã, mas aquele bar estava fechado, além disso Tarumã é monitorado por câmeras. Contou que eles vinham vindo em alta velocidade e foram parar quase na entrada de Assis, 20 km de Tarumã, quando cruzaram com viatura da força tática. Negou ter achado arma. Negou conhecer os réus. Esclareceu que teve contato com a vítima depois da abordagem, ela falou que usaram arma prateada e grande. Narrou que tirou as fotos dos réus no momento da abordagem, mostrou a foto dos acusados e das meninas que estavam no carro. Acrescentou que lhe passaram que os suspeitos usavam boné, camiseta e bermuda, falaram as características do veículo e disseram apenas dos dois. Afirmou que a vítima falou que soube destas meninas na hora, mas que já havia as visto antes, sabia que tinha mais alguém porque manobriram o veículo. Relatou que mandou as fotos dos réus sem máscara e depois fizeram o reconhecimento pessoal na Delegacia. Mencionou que a abordagem foi uns 20 minutos depois. Negou ter visto os réus dispensando algo no trajeto. Negou se lembrar da cor do boné, camiseta e máscara. Disse que eles negaram a arma de fogo. A testemunha Eduardo corroborou tais informações, trabalhava com o policial Álvaro e recebeu informação de que dois indivíduos tinham tentado roubar e um deles estaria armado com revólver. Contou que segundo os réus eles estavam em Tarumã, mas viu que eles vinham no sentido Florínea e o carro deles batia com o do responsável pelo roubo. Relatou que mandaram foto para equipe e a vítima confirmou que foram eles. Negou ter achado a arma de fogo no carro. Esclareceu que se posicionaram no trevinho da entrada de Tarumã, de Florínea até lá daria uns 15 a 20 minutos. Ressaltou que eles passaram em alta velocidade, acompanharam e os réus não pararam, conseguiram chegar próximo da divisa com Assis. Negou conhecer os réus. Frisou que mandaram a foto dos réus e das moças, a vítima negou ter visto mulheres. Negou ter enviado fotos de indivíduos semelhantes. Confirmou que passaram as características dos indivíduos e vestimentas, o relato foi que ambos estariam de boné, máscara de proteção, um com camiseta verde com boneco e outro com camiseta escura. Negou se recordar da cor do boné. Informou que mandaram fotos com máscara. Acrescentou que fizeram acompanhamento por 15 a 20 minutos e não os viu dispensando algo. A testemunha Celma afirmou que estava na cozinha lavando louça, escutou gritos e saiu correndo.

Relatou que viu um rapaz agredindo o esposo Davi, ficou muito nervosa. Mencionou que ele é meio alto, outro um pouco mais baixo, usava boné xadrez. Disse que chegou correndo e ele mandou calar a boca e chamou de vagabunda. Falou que o agressor da vítima estava armado. Negou ter ido à Delegacia fazer o reconhecimento. Negou ter visto direito a foto de fl.39, no dia dos fatos estava de noite e está muito nervosa, não se lembra direito porque foi muito correria, lembra que um usava boné xadrez e outro usava um claro. Contou que os ferimentos na foto de fl.40 foram da coronhada que o marido levou. Confirmou que um deles abordou e escutou seu marido falar que eles não entrariam. Informou que o vizinho escutou gritos, acendeu as luzes e eles correram. Narrou que eles usavam máscara e blusão. Confirmou que a máscara do que estava com o marido caiu. Negou saber quem estava dirigindo o carro, viu duas moças fora do carro sentadas na pracinha, elas entraram ao ver os réus e a vítima correndo. Acrescentou que no domingo os réus vieram lá. Disse que na delegacia tinha mais fotos e a depoente as viu, não tem como errar porque eles tinham vindo um dia antes e foi a depoente quem os atendeu, eles pegaram a cerveja e foram embora, tem parente aqui e foram num bar vizinho. Contou que as outras fotos que viu eram deles. Confirmou que o marido viu as meninas ao correr atrás dos réus. A testemunha Ana Carolina afirmou que no dia estava junto, foi na hora que seu avô foi guardar o carro. Relatou que foi para fora falar com ele e dois homens entraram, um abordando a vítima e outro no portão. Mencionou que o Laiola tinha arma, chegou apontando para seu avô, mandando ele ficar quieto, calar a boca e fechar o portão. Declarou que ele deu uma coronhada na cabeça do avô. Disse que nessa hora entrou para ligar para a tia pedir ajuda. Contou que o Laiola estava com um boné meio escuro, blusa preta ou cinza, calça, tênis e máscara preta, o outro estava com boné xadrez, blusa meio clara e máscara branca descartável. Confirmou que os objetos de fl.39 foram os usados pelos roubadores no dia do assalto. Negou conhecer o Laiola, mas ouviu comentários de que tem parente aqui. Informou que eles estavam num Golf prata, reconheceu a foto de fl.43 como o veículo. Falou que Laiola usava arma prata do cano fino e comprido. Negou ter tido contato com os réus, mas a depoente estava na porta da sala de casa, há mais ou menos um metro deles. Esclareceu que um estava com boné cinza e outro xadrez. Ressaltou que depois saiu na hora que o Davi correu atrás deles, viu o carro e aí voltou ligar para sua tia. Negou ter visto outras pessoas porque eles já tinham entrado no carro. Disse que prestou atenção no rosto e no olho deles. Afirmou ter ido na delegacia, apresentaram a foto deles, eles perguntaram como estavam, o modelo do carro, depois mostraram as fotos. Negou ter visto outras fotos além dos réus. Pois bem. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte das vítimas que legitimasse a tentativa de posse do veículo e pertences pelos réus. A inexistência de autorização torna certo que eles tentavam possuir “coisa alheia móvel”, elemento essencial do tipo penal e detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. Pela dinâmica obtida a partir da prova oral percebe-se que os réus deram início a um crime de roubo, abordaram Davi na garagem e o mandaram fechar o portão, ele se negou e nesse momento Carlos lhe deu uma coronhada com a arma na cabeça, o que resultou a lesão indicada na foto de fl.40. Houve um tumulto e o vizinho ouviu os gritos e acendeu a luz, os réus fugiram e entraram num veículo Golf cor prata, que estava na esquina. Em seguida a vítima acionou a polícia e os policiais avistaram os réus na entrada de Tarumã, vindo de Florínea, perseguiram eles até a entrada de Assis, onde fizeram a abordagem. Com eles nada de ilícito foi encontrado. Policiais enviaram fotos dos réus à vítima e testemunha, que os apontaram como os assaltantes e fizeram o reconhecimento pessoal. São de todo irrelevantes as pequenas divergências apontadas pela douta Defesa do réu Wellington, eis que as meninas que estariam no veículo Golf não são réus neste processo e não foram apontadas como partícipes. É irrelevante que a vítima e testemunhas as tenham visto ou não. A testemunha Ana Carolina esclareceu que correu atrás do avô e depois entrou na casa para ligar para a tia. Com relação à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico este Juízo conhece a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de que devem ser respeitadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal. Todavia, há elementos que permitem fazer um distinguishing, ou seja, não aplicar dado precedente vinculante por se reconhecer que a situação sub judice (aquela que

se está julgando imediatamente)

não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente. Ainda que a polícia não tenha enviado fotos de outras pessoas parecidas com a dos réus há que se ter em mente que elas foram tiradas numa rodovia, altas horas da noite, não era razoável exigir que a polícia parasse vários carros até achar pessoas parecidas com os réus para enviar várias fotos como preceitua o entendimento. Tampouco era razoável os policiais praticarem a famigerada prisão para averiguação sem ter certeza de que os réus eram os assaltantes. Além disso, ao contrário dos precedentes citados, essa abordagem ocorreu pouco tempo após os fatos e não horas depois. Ademais, outro fator de distinção é que a vítima Davi e a testemunha Ana Carolina atestaram que, antes de receber as fotografias dos réus, já tinham informado aos policiais as características dos roubadores e o veículo que eles usavam. Mais um elemento que é diferente dos julgados citados pelos Defensores é que houve a apreensão na posse dos réus de objetos que foram apontados pela vítima e testemunhas como os bonés, a máscara usados pelos assaltantes e o carro utilizado por eles durante a fuga. Assim, percebe-se sem nenhuma dificuldade que o caso aqui julgado é totalmente diferente daqueles em que as vítimas reconhecem alguém apenas com base em fotos e nada mais. Acrescente-se que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os dois assaltantes, tanto na fase inquisitória como em Juízo. A jurisprudência majoritária defende que em crimes deste jaez, em regra cometidos à revelia de terceiros, a palavra segura da vítima ao fornecer elementos de identificação dos criminosos é de suma valia, pois manteve contato direto e pessoal com eles. Nesse sentido, cite-se: Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los (Revista dos Tribunais, vol.606, p.357, rel. Costa Manso, destaquei). A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores (JTACrSP, vol.100, p.250, rel. Almeida Braga, destaquei). Embora os réus estivessem usando máscara no momento do crime a vítima atestou que durante o assalto a máscara caiu e foi possível ver o rosto deles. Tal relato foi corroborado pelo depoimento firme e seguro de Ana Carolina, a qual frisou que estava a cerca de um metro do local do crime, prestou atenção no rosto e nos olhos do assaltante que atacava seu avô. Não há motivo para duvidar desse reconhecimento, o qual não foi feito de forma genérica, apenas com base em cor de pele e estatura como sustentado nos debates. O depoimento também foi corroborado pelo relato de Celma, esposa da vítima. Embora ela estivesse visivelmente nervosa durante o depoimento, o que pode ser explicado pelo trauma causado pelo episódio, é certo que ela confirmou que um usava boné xadrez e outro usava um claro. Além disso, Davi e Celma ressaltaram que viram ambos os réus virem no bar no dia anterior aos fatos, o que certamente confere verossimilhança ao reconhecimento feito por eles. Ademais, a testemunha Ana Carolina confirmou que os bonés e as máscaras retratadas a fl.39 foram os usados pelos assaltantes durante o crime. A vítima Davi informou que um estava com boné escuro e outro com boné branco xadrez. Além disso, a vítima Davi e testemunha Celma falaram que os assaltantes fugiram num Golf cor prata. A testemunha Ana Carolina foi ainda mais específica e apontou o veículo retratado a fl.43 como o usado pelos assaltantes. As descrições dos bonés correspondem às dos apreendidos na posse dos réus, um era branco e xadrez e o outro cinza, mais escuro que o outro. A apreensão destes pertences na posse dos acusados, dentro do veículo Golf cor prata usado pelos assaltantes, não deixa dúvida alguma de que os dois estavam envolvidos no roubo. Outro elemento de convicção consiste no relato dos policiais Álvaro e Eduardo. Assim que souberam do roubo em Florínea eles se posicionaram no trevo de acesso a Tarumã e viram os réus vindo pela rodovia no sentido Florínea a Tarumã. Atestaram que os réus vinham em alta velocidade e só conseguiram fazer a abordagem na entrada de Assis, cerca de 15 a 20 minutos depois. Esta fuga pela rodovia corrobora ainda mais a certeza de que os dois cometeram o crime. A negativa de autoria apresentada pelos réus restou isolada nos autos e é inverossímil. Primeiro porque não explicaram o motivo pelo qual pessoas que sequer conheciam teriam

motivos para apontá-los como os assaltantes. Segundo porque eles mentiram quando falaram que estavam em Tarumã, eis que os policiais viram quando eles passaram por alta velocidade na entrada desta cidade, vindo da rodovia no sentido Florínea Tarumã. Terceiro porque não apresentaram nenhuma comprovação do alegado alibi. Não trouxeram em Juízo depoimento das moças que estavam com eles, de outros frequentadores do bar ou imagens das câmeras de segurança existentes em Tarumã. Pela dinâmica relatada em Juízo pela vítima extrai-se que o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Não resta dúvida acerca da caracterização da grave ameaça, inerente ao presente tipo penal. Apesar de não ter sido periciada a arma de fogo, tal circunstância não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena, como se observa pelo seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPAROS. ORDEM DENEGADA. 1. O roubo qualificado dispensa a apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 05.06.2009). 2. In casu: a) os pacientes, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram diversos bens da vítima, um moto taxista, dentre os quais, o capacete que portava, dinheiro e documentos; b) a vítima foi atacada com socos e chutes, e com uma arma de fogo, utilizada para agredi-la fisicamente e ameaçá-la durante o tempo em que durou a ação delituosa. 3. É cediço na Corte que: "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03.09.2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11.06.2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16.04.2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01.02.2011, DJe 09.03.2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26.06.2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04.12.2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.12.2010, DJe 08.02.2011). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.910/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux. j. 08.11.2011, unânime, DJe 05.12.2011, destaquei). Por fim, resalto ser irrelevante o fato de a polícia não ter visto os réus dispensando objetos como a arma de fogo. É certo que os réus não foram perseguidos pela polícia entre Florínea e Tarumã e é bem possível que durante o trajeto tenham dispensado arma de fogo e roupa de frio. No caso vertente deve ser aplicado o tipo penal da tentativa, formado com a aplicação do art. 14, inciso II, do Código Penal. Os réus deram início à execução do roubo, mas por circunstâncias alheias à vontade dele o crime não se consumou, não chegando a res furtiva a sair da esfera de vigilância do proprietário. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não

restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Portanto, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos requeridos nas penas do crime de roubo é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas

pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício dos réus não militam quaisquer justificativas ou dirimentes: a) réu Carlos Eduardo: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é elevadíssima, eis que o réu demonstrou audácia ao invadir residência habitada para cometer o roubo, o que tem o potencial de causar trauma e grande sensação de intranquilidade para a vítima. Acertadamente o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que (...) “o domicílio é Constitucionalmente previsto como asilo inviolável, pois é o lugar em que as pessoas se abrigam, e, não há sensação maior de impotência e insegurança, do que quando se tem sua residência invadida, mormente durante a madrugada, que naturalmente já há a diminuição da vigilância” (STJ, REsp 1604547/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 01/08/2017). Em outro julgado a mesma corte decidiu que: (...) “1. Não há ilegalidade na consideração negativa da culpabilidade, pois o Juiz destacou que o paciente compôs grupo de três agentes - número superior ao exigido para configurar o concurso - e praticou o roubo na residência da vítima, revelando maior ousadia e periculosidade. 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. (...)” (STJ, HC 309.243/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, DJE 11/09/2015). Percebe-se que a esposa da vítima ficou visivelmente traumatizada com o ocorrido. O réu é duplamente reincidente e possui outra condenação definitiva por extorsão, conforme certidão juntada aos autos. Pode uma destas ser utilizada como mau antecedente sem caracterizar *bis in idem* por se tratar de fatos distintos. De acordo com a doutrina mais abalizada, (...) “nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nesta hipótese, *bis in idem*, pois são elementos geradores diversos” (Nucci, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 6ª ed., rev.. atual e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.167). O C. Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. (...) 3. De acordo com entendimento desta Corte, “havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou *bis in idem* qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência” (REsp n. 1.596.509/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Os motivos do crime foram inerentes ao tipo, não o prejudicando. O comportamento do ofendido não levou o réu à prática deste delito. Na primeira fase, após considerar tais elementos, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase não há atenuantes a considerar. Ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Reconheço também a do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, o que justifica incremento de 1/6 (um sexto). Entendo que há uma relação com o crime de roubo, pois a pandemia diminuiu o fluxo de cidadãos e de policiais nas ruas e com certeza facilitou a prática deste tipo de crime. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-

19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Considerando as duas agravantes, majoro a pena no total de 1/3 (um terço) para 07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 17 (dezesete) dias-multa. Na terceira fase considerando o concurso de agentes majoro a pena em 1/3 (um terço) e a fixo em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Ainda nesta fase é caso de efetuar novo aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. A Lei nº 13.654, de 2018, passou a tipificar o emprego de arma de fogo no §2º-A do art. 157, adotando tratamento mais gravoso para esta qualificadora, ao cominar aumento de pena à fração de 2/3. Tal dispositivo veio recrudescer a situação daquele que pratica gravíssimo delito de roubo valendo-se de arma de fogo na empreitada criminosa. Tem-se que as aventadas qualificadoras se encontram, após a alteração legislativa, previstas em parágrafos distintos e estabelecem graus de aumento diversos: enquanto à comparsaria comina-se aumento de 1/3 até a metade, ao uso de arma de fogo o aumento se dá, diga-se novamente, à fração fixa de 2/3. Com alteração legislativa, necessário que sejam tais majorantes valoradas separadamente, a afastar a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em casos como o presente. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza, sob o ângulo literal, apenas uma faculdade de o julgador, na hipótese de concurso entre causas de aumento e entre causas de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição. Não se trata de obrigatoriedade, mas de mera faculdade disposta ao julgador. Segundo o ilustre Professor Edilson Mougenot Bonfim: "Nos termos do parágrafo único do artigo 68, do CP, o juiz pode limitar-se à aplicação da causa que mais aumente, desprezando as demais (trata-se de faculdade do juiz)" (BONFIM, Edilson Mougenot, Fernando Capez, Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 728). Entendo que o delito de roubo praticado por mais de um agente e com emprego de arma de fogo merece reprimenda mais severa do que, por exemplo, o delito de roubo cometido apenas com a majorante do emprego de arma de fogo. Não fosse uma mera faculdade do juiz a disposição contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estaríamos destinando tratamento igual a situações desiguais e violando o princípio constitucional da individualização das penas que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Nesse sentido é a lição de André Estefam: "(...) todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da Parte Especial, serão obrigatórias quando houver só uma causa de aumento e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa da mesma natureza na Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução". (ESTEFAM, André, Direito Penal: Parte Geral. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 447-448). A jurisprudência corrobora a possibilidade de dupla incidência de causas de aumento de pena: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas

na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa de dosimetria, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior reprovabilidade da conduta. (...) (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 667.433 - SC, 6ª Turma, Rel. Min. Convocado Olindo Menezes, j.22/02/2022, destaquei). Ressalto que a gravidade concreta e maior reprovabilidade da conduta, exigida pelo Superior Tribunal de Justiça para dupla incidência ficaram escancaradas nos autos, eis que a arma de fogo foi usada para praticar violência física contra a vítima. Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal também admite esta forma de fixar a pena: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102,

I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) (STF. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 19/08/2014, DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014, destaquei). PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM'S. ROUBO MAJORADO, RECEPÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 157 §2º, II E § 2º-A, I E 180 DO CP E 14 DA LEI 10.826/03. ANÁLISE EM ASSENTADA ÚNICA, ANTE A CONVERGÊNCIA DOS ARGUMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS E PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ARRIMADA EM UM VETOR INIDÔNEO (CONSEQUÊNCIAS). DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DADA A SUBSISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, CUJO RESULTADO FINAL NÃO DESBORDA DA DIRETRIZ DE 1/8 SUGERIDA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CÚMULO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, SOBRETUDO COM A EDIÇÃO DA LEI 13.654/18. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME A SEREM EXAMINADAS NO JUÍZO EXECUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJRN. Apelação Criminal nº 2019.001632-4, Relator: Des. Saraiva Sobrinho. Julg. 05/11/2019, destaquei). Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços) pela presença da majorante do emprego de arma de fogo e a elevo para 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. Por fim, a diminuição relativa à tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal) deve atender ao critério do caminho já percorrido pelo agente na prática do delito (iter criminis), ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito menor será o abatimento. Levando-se em conta os atos executórios praticados, inclusive com violência física contra a vítima, e a proximidade da consumação, deve a pena ser diminuída em 1/3 (terço), atingindo o patamar definitivo de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada na ocasião do interrogatório e do salário mínimo vigente quando dos fatos, valor que deverá ser atualizado até o pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, ante o montante da pena e a grave ameaça exercida. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, considerando a reincidência, o total da pena e gravidade concreta do delito. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na

medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Considerando a pena acima fixada, o réu somente faria jus à progressão de regime para o semiaberto após o cumprimento de 30% da pena, o que não ocorreu. Assim, apesar da detração, o regime inicial de cumprimento da pena restante será o fechado. b) réu Wellington: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é elevadíssima, eis que o réu demonstrou audácia ao invadir residência habitada para cometer o roubo, o que tem o potencial de causar trauma e grande sensação de intranquilidade para a vítima. Acertadamente o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que (...) "o domicílio é Constitucionalmente previsto como asilo inviolável, pois é o lugar em que as pessoas se abrigam, e, não há sensação maior de impotência e insegurança, do que quando se tem sua residência invadida, mormente durante a madrugada, que naturalmente já há a diminuição da vigilância" (STJ, REsp 1604547/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 01/08/2017). Em outro julgado a mesma corte decidiu que: (...) "1. Não há ilegalidade na consideração negativa da culpabilidade, pois o Juiz destacou que o paciente compôs grupo de três agentes - número superior ao exigido para configurar o concurso - e praticou o roubo na residência da vítima, revelando maior ousadia e periculosidade. 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. (...)" (STJ, HC 309.243/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, DJE 11/09/2015). Percebe-se que a esposa da vítima ficou visivelmente traumatizada com o ocorrido. O réu é triplamente reincidente por roubo, conforme certidão juntada aos autos. Pode uma destas ser utilizada como mau antecedente sem caracterizar bis in idem por se tratar de fatos distintos. De acordo com a doutrina mais abalizada, (...) "nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nesta hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores diversos" (Nucci, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 6ª ed., rev.. atual e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.167). O C. Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. (...) 3. De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Os motivos do crime foram inerentes ao tipo, não o prejudicando. O comportamento do ofendido não levou o réu à prática deste delito. Na primeira fase, após considerar tais elementos, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase não há atenuantes a considerar. Ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a

reincidência de Wellington é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por roubo e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, pois tal prática "demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa". No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A